

次のⅠからⅢまでの【見解】は、被告人の特定に関する基準について述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に、後記【事例】について、検察官から刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求された裁判所の採るべき対応として正しいものは、後記1から6までのうちどれか。(改)

【見 解】

- Ⅰ. 検察官が実際に起訴しようとした者が、だれであるかを基準とする。
- Ⅱ. 起訴状に被告人として氏名を表示された者が、だれであるかを基準とする。
- Ⅲ. 現に公判廷において被告人として行動した者が、だれであるかを基準とする。

【事 例】(改)

甲は、強盗罪で拘禁刑の実刑判決を受けて刑務所に服役し、その刑の執行を終えた。その後、甲は、無銭飲食による詐欺事件(①事件)を起こして逮捕勾留されたが、その際、身上等を知る乙の氏名等を詐称したため、検察官は、乙の氏名等を詐称している甲を犯人と考えて、その勾留中に、起訴状の被告人を乙と表示して詐欺罪で起訴した。裁判所は、乙の氏名等を詐称している甲を公判期日に出頭させて審理した上、拘禁刑に処するとともに、その刑の執行を猶予する旨の判決を宣告し、同判決は確定した。

さらに、甲は、自動車運転による業務上過失傷害事件(②事件)を起こして身柄不拘束で警察官の取調べを受けたが、その際、身上等を知る丙の氏名等を詐称した。甲から打ち明けられて事情を知った丙が、甲に代わって検察庁に出頭し検察官の取調べを受けたため、検察官は、丙を犯人と考えて、在宅のまま、起訴状の被告人を丙と表示して業務上過失傷害罪で起訴した。裁判所は、丙を公判期日に出頭させて審理した上、拘禁刑に処するとともに、その刑の執行を猶予する旨の判決を宣告し、同判決は確定した。

その後、甲は、窃盗事件を起こして現行犯逮捕され、同事件の逮捕勾留中も身上等を知る丁の氏名を詐称したものの、甲を取り調べた検察官が、その供述内容に不審を抱き捜査を遂げた結果、現在勾留中の被疑者は甲であること、甲は①事件では乙の氏名等を詐称し、②事件では丙の氏名等を詐称していたこと及びいずれの事件の判決の宣告も前記強盗罪の刑の執行を終わった日から5年を経えていなかったことが判明した。このため、検察官は、裁判所に対し、刑法第26条第3号により、甲に執行猶予の必要的取消事由が存することを理由に、①事件及び②事件における刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求した。

1. Ⅰの考え方に立てば、①事件は請求を却下し、②事件は執行猶予を取り消すべきである。
2. Ⅰの考え方に立てば、①事件及び②事件とも請求を却下すべきである。
3. Ⅱの考え方に立てば、①事件は執行猶予を取り消し、②事件は請求を却下すべきである。
4. Ⅱの考え方に立てば、①事件及び②事件とも執行猶予を取り消すべきである。
5. Ⅲの考え方に立てば、①事件は執行猶予を取り消し、②事件は請求を却下すべきである。
6. Ⅲの考え方に立てば、①事件及び②事件とも執行猶予を取り消すべきである。

検察官が公訴提起の対象とした者と、起訴状に被告人として表示された者と、公判廷に出頭して被告人として行動する者とは一致するのが常態であるが、齟齬が生じることもある。その場合誰が被告人となるか（被告人の特定の基準）につき、①起訴状の表示によるべきであるとする（形式的）表示説、②検察官の意思によるべきであるとする意思説、③被告人として行動し、又は取り扱われたかどうかによるべきであるとする行動説の3説が対立する。

本問の見解Ⅰは意思説、見解Ⅱは（形式的）表示説、見解Ⅲは行動説である。

なお、裁判実務上は、概ね、起訴状の表示を基本としつつも、表示のみによることから生じる不当な結果を是正するため、検察官の意思や被告人としての行動をも考慮に入れて被告人を決する実質的表示説によって動いているとされている。

1 誤っている

見解Ⅰ（意思説）に立った場合、①事件の被告人は検察官が実際に取り調べ、起訴しようとした甲である。そして、甲は①事件につき刑の執行猶予の言渡しを受けているが、以前別の強盗罪で拘禁刑に服していることから「猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられた」（刑法26条3号）場合に当たる。この場合、裁判所は執行猶予の取消し（刑法26条）をすべきである。よって、本記述前段は誤っている。同様に考えると、②事件については、検察官が実際に取り調べ、起訴しようとした丙が被告人となる。刑の執行猶予の言渡しの効力は丙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述後段も誤っている。したがって、本記述は誤っている。

2 誤っている

見解Ⅰ（意思説）から検討すると、①事件の被告人は検察官が実際に取り調べ、起訴しようとした甲である。甲は①事件につき刑の執行猶予の言渡しを受ける以前に別の強盗罪で拘禁刑に服しており、「猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられた」（刑法26条3号）場合に当たる。この場合、裁判所は執行猶予の取消し（刑法26条）をすべきである。よって、本記述前段は誤っている。同様に、②事件については、検察官が実際に取り調べ、起訴しようとした丙が被告人となる。刑の執行猶予の言渡しの効力は丙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述後段は正しい。したがって、本記述は誤っている。

3 誤っている

見解Ⅱ（形式的表示説）に立った場合、①事件の被告人は起訴状に氏名が記載された乙である。刑の執行猶予の言渡しの効力は乙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述前段は誤っている。同様に考えると、②事件の被告人は起訴状に氏名が記載された丙である。刑の執行猶予の言渡しの効力は丙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合も、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述後段は正しい。したがって、本記述は誤っている。

4 誤っている

見解Ⅱ（形式的表示説）に立った場合、①事件の被告人は起訴状に氏名が記載された乙である。刑の執行猶予の言渡しの効力は乙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述前段は誤っている。同様に考えると、②事件の被告人は起訴状に氏名が記載された丙である。刑の執行猶予の言渡しの効力は丙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合も、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述後段も誤っている。したがって、本記述は誤っている。

5 正しい

見解Ⅲ（行動説）に立った場合、①事件の被告人は現に公判廷に被告人として出頭した甲である。甲は①事件につき刑の執行猶予の言渡しを受ける以前に別の強盗罪で拘禁刑に服しており、「猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられた」（刑法26条3号）場合に当たる。この場合、裁判所は執行猶予の取消し（刑法26条）をすべきである。よって、本記述前段は正しい。同様に、②事件においては公判廷に被告人として出頭した丙が被告人となる。刑の執行猶予の言渡しの効力は丙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述後段も正しい。したがって、本記述は正しい。

6 誤っている

見解Ⅲ（行動説）に立った場合、①事件の被告人は現に公判廷に被告人として出頭した甲である。甲は①事件につき刑の執行猶予の言渡しを受ける以前に別の強盗罪で拘禁刑に服しており、「猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられた」（刑法26条3号）場合に当たる。この場合、裁判所は執行猶予の取消し（刑法26条）をすべきである。よって、本記述前段は正しい。同様に、②事件においては公判廷に被告人として出頭した丙が被告人となる。刑の執行猶予の言渡しの効力は丙に生じるため、検察官は別人である甲の事情に基づき執行猶予の取消しを請求することはできない。この場合、裁判所は請求を却下すべきである。よって、本記述後段は誤っている。したがって、本記述は誤っている。

